



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4472/2017/1/CA1

Paraná, 8 de mayo de 2017.

Y VISTOS, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Presidente; la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Vicepresidenta, y el Dr. David Alejandro CHAULET, Juez de Cámara Subrogante, en el Expte. N° FPA 4472/2017/1/CA1, caratulado: **"LEGAJO DE APELACIÓN DE PINCHEIRA, DIEGO MATIAS EN AUTOS PINCHEIRA, DIEGO MATIAS POR INFRACCION LEY 23.737"**, provenientes del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y;

DEL QUE RESULTA:

El Dr. Daniel Edgardo Alonso, dijo:

Que llegan estos actuados a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Sra. Fiscal Federal contra la resolución adoptada en la Audiencia oral inicial de Flagrancia -art. 353 ter, 2° párrafo ley 27.272- de fecha 04 de abril de 2017, cuya acta obra a fs. 40/41 de las presentes, en cuanto dispone aplicar al caso el precedente Arriola esto es el consumo personal no punible, remitiéndose a los argumentos allí vertidos; declara la inconstitucionalidad del art. 14 2da. parte de la ley 23.737, impone las costas de oficio, ordena la destrucción del material estupefaciente, y da por concluida la acción penal,



sobresee al imputado Diego Matías Pincheira y dispone su libertad. El recurso fue concedido en la audiencia señalada.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del CPPN, de la que da cuenta el acta de fs. 55 y vta., compareciendo en dicha oportunidad el Sr. Fiscal General de Cámara, Dr. Ricardo Carlos María Álvarez; y el Sr. Defensor Público Coadyuvante, Dr. José Alberto Boxler, en defensa de Diego Matías Pincheira, quedando los autos en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- a) Que, el Sr. Fiscal celebra la celeridad y oportunidad de la tramitación de estas actuaciones. Alude al procedimiento de flagrancia y refiere al hecho que se investiga. Menciona el proceder de la fuerza y los lugares donde fueron habidos los estupefacientes y la cantidad.

Sostiene que pudo haberse imputado a todos los que se encontraban en el automóvil o a alguno de ellos, lo que podría dar lugar a una Tenencia compartida de estupefacientes cuyo destino sea su consumo personal. Aduce que, en ese supuesto, todos serían coautores y no habría terceros, y sus conductas podrían considerarse irrelevantes según la doctrina del fallo Arriola.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4472/2017/1/CA1

Destaca que la Fiscal sólo imputó a Pincheira y le atribuyó la tenencia simple de estupefacientes. Efectúa consideraciones respecto de lo manifestado por el imputado e indica lo resuelto por el magistrado. Considera que la resolución es arbitraria y debe ser revocada.

Subraya que es evidente que quienes se conducían con el imputado debe ser considerados terceros, por lo que torna relevante la conducta que se le imputa a Pincheira, resaltando el lugar donde se encontraron los cigarrillos, lo que permite concluir que el convite estaba a su alcance. Concluye que por las circunstancias del caso no corresponde a la doctrina del fallo Arriola.

Solicita se revoque la resolución recurrida y continúen los autos según su estado.

b) Por su parte, el Sr. Defensor Público Coadyuvante considera correcta la calificación jurídica adoptada por el Magistrado.

Destaca que la cantidad era escasa y refiere a los dichos del imputado que dan cuenta que su destino era pura y exclusivamente para su consumo personal. Resalta que los cigarrillos estaban dentro de un estuche metálico y una bolsa Ziploc. Efectúa consideraciones respecto de la trascendencia a



terceros y refiere a la esfera privada protegida por el art 19 de la CN.

Concluye que la resolución es ajustada a derecho y cita el fallo Arriola. Reitera que del acta de procedimiento no se advierte que haya desplegado una conducta que afecte a terceros y destaca que no obran los testimonios de los demás acompañantes que señalen que los haya convidado. Alude al peligro concreto y resalta que no se probó el convite, que los tóxicos no estaban a simple vista y que se necesitó el pasaje de un can y la posterior requisa para advertirlos.

Concluye que la tenencia no trajo aparejado un perjuicio concreto a los bienes o a terceros y solicita se rechace el recurso y se confirme la resolución.

II- Que, las actuaciones principales reconocen su inicio el día 03/04/2017, en ocasión de que personal de Gendarmería Nacional que se encontraba realizando tareas de seguridad vial y contralor físico y documentológico de vehículos en la Ruta Nacional N° 14, km. 124,5, Concepción del Uruguay, detiene al automotor Renault, modelo Master, dominio MKZ-005, conducido por Maximiliano Di Chiara, acompañado por Maximiliano Carlos Cucurull y Diego Matías Pincheira. Al requerirle





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4472/2017/1/CA1

documentación, el can detector de narcóticos *"se puso nervioso y comenzó a indicar la presencia de estupefacientes en el vehículo"*. En virtud de lo dispuesto por el art. 230 bis del CPPN se requirió la presencia de testigos y se invitó a los pasajeros a que exhiban sus pertenencias. Allí se constató que en la mochila de Pincheira la presencia de un trozo de marihuana -36,5 gr.-, en el portavasos delantero se encontró una bolsa con igual sustancia -1 gr.- y un estuche que contenía 5 cigarrillos armados de marihuana -2,5 gr.-.

La fuerza preventora se comunicó con la Sra. Fiscal Federal quien consideró aplicable la ley 27.272, por lo que ordenó la sustanciación de la prevención sumaria y la detención de Pincheira, entre otras medidas. Anoticiado del hecho, el Sr. Juez a-quo dispuso el traslado del nombrado al Juzgado.

El día 04/04/2017 se realizó la audiencia prevista en el art. 353 ter., 2º párrafo del CPPN -ley 27.272- y, luego de ser indagado, y a pedido de la defensa, el magistrado resolvió aplicar al caso el precedente *"Arriola"*, remitiéndose a los argumentos allí vertidos; declaró la inconstitucionalidad del art. 14 2da. parte de la ley 23.737, impuso las costas de oficio, ordenó la



destrucción del material estupefaciente, dio por concluida la acción penal, sobreseyó al imputado Diego Matías Pincheira y dispuso su libertad. Contra tal decisión se alzó el MPF, dando lugar a esta Alzada.

III- a) Sentado aquello, comenzaré el tratamiento de la cuestión haciéndome nuevamente eco de las palabras del Señor Fiscal General ante esta Cámara relacionadas a la satisfacción que produce advertir como los operadores del derecho comienzan a perder el miedo al cambio de paradigma y profundizan la aplicación del procedimiento instituido por Ley 27272 a casos que -como el presente- califican sobradamente para ello.

Ahora bien, como todo nuevo sistema, su implementación no sólo provoca resistencias, sino también errores. Sin embargo, el único error imperdonable sería sucumbir ante el temor de lo desconocido y refugiarnos en la comodidad de la denominada "zona de confort", definiendo a esta última como la que nos permite sentir un máximo de seguridad en nuestras acciones.

En el caso que nos ocupa -como bien lo ha señalado el Fiscal General-, se advierten sin mayores esfuerzos diversos yerros del Señor "Juez de Garantías" y de la Fiscal ante la anterior instancia





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4472/2017/1/CA1

que -desde ya anticipó- me llevarán a proponer al acuerdo la revocación de la resolución recurrida.

El primer yerro -atribuible a la Fiscal- consiste en haber imputado el hecho pura y exclusivamente a Diego Matías Pincheira sin explicar mínimamente porque ha seleccionado a éste cuando, al menos una parte de lo secuestrado, se presentaba en condiciones de ser atribuido a uno, a dos o a los tres tripulantes del vehículo.

La circunstancia de que Pincheira llevará en su mochila la parte más importante y aún el hecho de que este se hiciera cargo de todo lo secuestrado lejos está -en función de la situación fáctica- de liberar a los demás tripulantes sin preguntarse ni por un solo momento sobre su eventual rol en el evento. Y con esto no pretendo atribuir responsabilidad a Di Chiara y/o Cucurrul, lo que por otra parte no me viene permitido dado que en este procedimiento es el Ministerio Público Fiscal quien debe 'imputar' y posteriormente probar, sino que -como hemos de ver-, la determinación del rol de Di Chiara y Cucurrul resulta fundamental -atento la modalidad de verificación de la tenencia- para determinar -en caso de enrostrarse el tipo privilegiado- si la tenencia verificada habrá de resultar punible.

Fecha de firma: 08/05/2017

Alta en sistema: 09/05/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: BERNARDO JOSÉ ARANGUREN, SECRETARIO DE CÁMARA



#29653602#178093765#20170508125745365

El Fiscal General ha analizado adecuadamente las diversas situaciones en las que podrían haberse hallado Di Chiara y Cucurrul respecto de la tenencia atribuida a Pincheira. Si ambos son extraños a esta tenencia, serían terceros respecto de los cuales la tenencia que se atribuye a Pincheira podría dejar de ser considerada intrascendente y por tanto inocua. Si ambos resultaran tenedores en forma conjunta con el imputado, ostentarían el carácter de coautores y como tales no serían terceros. Si uno solo de ellos hubiese tenido con Pincheira, el otro sería tercero con las posibles consecuencias arriba consignadas.

Es por ello que ha errado el Ministerio Público Fiscal de Concepción del Uruguay al conformarse con la sola imputación a Pincheira sin detenerse un solo momento a considerar el de sus acompañantes. Este yerro fue hábilmente aprovechado por la Defensa Pública Oficial que solícitamente se encargó de consentir el procedimiento en flagrancia -consentimiento innecesario dado que la ley establece la posibilidad de oponerse, más no requiere un consentimiento expreso del imputado o su defensa-, asumió acto seguido la responsabilidad a título de tenencia para consumo personal y a partir de allí introdujo la cuestión relativa a la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4472/2017/1/CA1

inconstitucionalidad de la norma y el consecuente pedido de sobreseimiento.

Por si algún error faltara, el "Juez de Garantía" -sin respetar la bilateralidad y contradicción prevista en el art. 353 bis del CPPN -texto según Ley 27272-, resolvió sin más trámite acogiendo íntegramente el planteo de la defensa, provocando un vicio que -finalmente quedó consentido- ante un nuevo error de la Fiscal que no cuestionó la falta de vista del sorpresivo planteo, limitándose a apelar la resolución que es objeto de revisión por esta Cámara.

b) Ingresando al recurso de apelación propiamente dicho y tal como ya anticipara, debo propiciar al acuerdo su parcial acogimiento y digo "parcial" porque más allá de los efectos de la resolución que propongo, resulta impertinente pretender que esta Cámara califique el hecho en forma alguna.

La primera razón de tal impertinencia -aunque no la más relevante- es que el Señor Fiscal General omitió deliberadamente sostener ese agravio concreto -seguramente consiente de lo que luego expondré-, omisión ésta que no pasó desapercibida para el Defensor Oficial ante esta Cámara que ab



inicio intentó obtener una expresión concreta de parte de su adversa.

Pero lo más relevante es que en este procedimiento no existe -como en el procedimiento común- un auto de procesamiento. Ello así, quien califica el hecho es el Fiscal y el Juez sólo podrá ingresar en el punto si como consecuencia de la petición Fiscal debe resolver respecto de la prisión preventiva, en tal caso, por imperio del art. 316 del CPPN, aplicable al caso.

En ese contexto, resulta impertinente en el caso concreto pretender que ésta Cámara revise la calificación, máxime teniendo en cuenta la forma en que he de proponer al Acuerdo se resuelva. Todo esto dicho sin perjuicio de considerar los límites de una eventual *reformatio in pejus*. Y adentrándonos a la cuestión medular debo manifestar que la resolución recurrida en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad y consecuente sobreseimiento debe ser revocada por prematura.

Ocurre que ante los yerros de la Fiscal y del Juez de Garantías arriba apuntados no tenemos convicción alguna respecto de los roles de Di Chiara y Cucurrul en el evento pero, si para el Ministerio Público estos eran ajenos al hecho, no queda otra posibilidad que concluir que eran 'terceros'. Ello





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4472/2017/1/CA1

así -al menos lo transportado en el portavasos- tenía aptitud para trascender a estos 'terceros', supuesto en el cual no procedería la aplicación de la doctrina del caso "ARRIOLA".

Así las cosas y de conformidad a la interpretación armónica de los arts. 334 y 335 del CPPN -que exige certeza negativa-, la resolución debe ser revocada disponiendo que el Juez de Garantías dentro del término de 24 horas de recibida la causa continúe la audiencia prematuramente abortada, otorgando a las partes la posibilidad de ofrecer y producir la prueba que estimen necesaria en pos de sus respectivas postulaciones.

Finalmente y habiéndose provisto al Juzgado de las cámaras de video provistas por el Consejo de la Magistratura de la Nación y existiendo a disposición el software necesario para su funcionamiento, la audiencia debe celebrarse -como así, las que en el futuro se celebren en todas las causas de flagrancia- deberán ser registradas en audio y video, haciéndose responsable al Magistrado actuante en caso de incumplimiento de lo aquí dispuesto.

La **Dra. Cintia Graciela Gomez**, dijo: I..., II..., III- Que a efectos de la resolución de la cuestión, corresponde señalar que el Máximo Tribunal



en la causa "Arriola", resuelve la declaración de inconstitucionalidad del art. 14, segunda parte, de la ley 23737, en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso personal que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros.

Ello así, deberá atenderse al contexto y ámbito en el que el encausado detentaba el tóxico, esto es, en la vía pública a bordo de un rodado en el que se trasladaba junto a otras personas.

Que de tales circunstancias se deriva que la conducta desplegada por el nombrado no ha de ser contemplada por el aludido precedente de la CSJN por falta de afectación al bien jurídico protegido por la norma.

Que según la doctrina invocada, es un presupuesto que la tenencia con fines de consumo sea escasa, se dé en condiciones de privacidad y que no exista posibilidad concreta de afectación a terceras personas, lo que en el caso y por el momento, no puede ser afirmado.

Ello pues en el presente, la conducta desplegada por Pincheira aparece *prima facie* con suficiente aptitud para afectar el bien jurídico tutelado, o aparejar un peligro concreto o un daño a





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 4472/2017/1/CA1

derechos o bienes de terceros, lo que le quita al comportamiento analizado el carácter de acción privada protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional.

Por estos fundamentos, estimo que la resolución apelada ha de ser revocada, debiendo continuar los autos según su estado.

El **Dr. David Alejandro Chaulet**, dijo: Que, adhiere a la solución propuesta por el Dr. Alonso.

Que, en mérito al resultado del acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

I- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la Sra. Fiscal General y, en consecuencia, revocar la resolución adoptada en la Audiencia oral inicial de Flagrancia de fecha 4 de abril de 2017, cuya acta obra a fs. 40/41 de las presentes, en cuanto declara la inconstitucionalidad del art. 14 2da. parte de la ley 23.737 y sobresee al imputado Diego Matías Pincheira, en virtud de los fundamentos expuestos (art. 455 del CPPN).

II- Disponer que el Juez de Garantías dentro del término de 24 horas de recibida la causa continúe la audiencia prematuramente abortada, otorgando a las partes la posibilidad de ofrecer y producir la prueba que estimen necesaria en pos de sus respectivas postulaciones.



III- Encomendar al Magistrado a-quo que tenga presente lo apuntado en el último párrafo del considerando III- b).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

Se deja constancia que la Dra. Cintia G. Gómez estuvo presente en la deliberación, no suscribiendo la presente de conformidad a lo establecido en el art. 399, 2° párr. del C.P.P.N. y al art. 109 del R.J.N

DANIEL EDGARDO ALONSO

DAVID ALEJANDRO CHAULET

ANTE MI

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
SECRETARIO DE CÁMARA

